

1501308-14.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501308-14.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000962

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2228226/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19775108 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2303/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2228226 - 02º D.P. PIRACICABA, 2303/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON APARECIDO BEISSMAN

Réu Preso

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 16:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: GILSON APARECIDO BEISSMAN - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM GUSTAVO PHATRICY NICOLAU SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM RICARDO VICTORIA DE CAMARGO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha PM GUSTAVO PHATRICY NICOLAU SILVA.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM RICARDO VICTORIA DE CAMARGO, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM

RICARDO VICTORIA DE CAMARGO, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Após, o réu GILSON APARECIDO BEISSMAN foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "GILSON APARECIDO BEISSMAN, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 99/101. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 136), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 140/147), sendo a denúncia recebida (fls. 153/156). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, fotografia de fls. 16 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 122/124. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento de rotina, quando, em determinado momento, no local dos fatos, avistou o réu sozinho na via. Afirmou que, quando o acusado visualizou a aproximação da viatura, adentrou rapidamente num terreno vazio e tentou fugir. Disse que rapidamente desembarcou da viatura e conseguiu alcançar e deter o réu ainda no terreno em comento. Relatou que, após revista pessoal, encontrou na posse do acusado cinquenta e quatro porções de "crack" e uma porção de maconha, bem como dinheiro em espécie e dois telefones celulares. Aduziu que, uma vez questionado de maneira informal, o réu não quis se manifestar sobre os fatos. Por fim, esclareceu que, antes da apresentação da ocorrência, quando o réu solicitou permissão para usar o banheiro, conseguiu alcançar um dos telefones celulares em comento e o quebrar[1], não tendo explicado o porquê quebrou o aparelho. No mesmo sentido foram as palavras do policial militar Ricardo Victoria de Camargo, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que não é traficante, mas mero usuário, sendo que, no dia dos fatos, estava no local para comprar drogas. disse que trocou um aparelho celular por 54 pedras de crack. Contrariando-se, em seguida mudou a versão, alegando que estava resetando o aparelho trocado quando apareceram os policiais. Disse que na delegacia tentou quebrar o aparelho celular "por raiva". Entretanto, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonantes e isoladas das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. Alias, a versão apresentada em Juízo contradiz o alegado pelo próprio acusado na fase inquisitiva. De fato, perante a autoridade policial o acusado apresentou outra versão, alegando que se assustou com a viatura, adentrou num terreno, onde funciona o ponto de venda de drogas e avisou o olheiro do tráfico. Disse que o traficante jogou a droga no chão e correu, conseguindo fugir. Disse que foi abordado na sequência e que iria comprar vinte reais de crack e tentar trocar seu telefone celular por drogas. Outrossim, é certo que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o acusado trazia consigo 54 porções de cocaína na forma de crack e uma porção de maconha, quantidade essa que não se coaduna com a de um simples usuário. Ademais, o acusado tentou se evadir ao avistar a viatura policial e tinha consigo também, além das drogas, vinte reais em dinheiro e dois aparelhos celulares, tendo inclusive tentado quebrar, com sucesso, um dos aparelhos, circunstâncias essas que, acrescidas à quantidade de pedras de crack consigo apreendidas, nitidamente indicam que estava ele no local traficando, e não apenas usando drogas. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se

produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que as circunstâncias judiciais são neutras na primeira fase. Na segunda fase, verifica-se que o réu é multireincidente, inclusive específico (autos nº 0000926-37.2017 - fls. 116; 0006803-09.2020 - fls. 116/117; 0009588-46.2017 - fls. 117/118; 0009631-80.2017 - fls. 118; e 0020529-02.2010 - fls. 119/120). Na terceira fase, ante a reincidência específica, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 20,00 (vinte reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial. [1] O que foi confirmado pelos laudos periciais de fls. 188/191 e 192/197".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Gustavo, Policial Militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro quando, ao entrarem na rua descrita na denúncia, avistaram o réu. Ao ver a viatura, ele tentou correr para um terreno baldio, mas foi abordado. Em busca pessoal, encontraram 54 pedras de crack e uma porção de maconha, além de R\$ 20,00 em dinheiro. O acusado nada disse sobre as drogas. Depois da abordagem do acusado, uma senhora se aproximou e disse que era esposa do réu, mas nada de ilícito foi encontrado com ela. Além dela, não havia outras pessoas no local. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Também foram apreendidos dois celulares. No Plantão Policial, o réu disse que precisava ir ao banheiro. Nesse momento, ele pegou um dos objetos e arremessou no chão, destruindo-o. Ele não disse o motivo pelo qual fez isso. O réu, em interrogatório, declarou que é usuário de crack. Alguns dias antes dos fatos, tinha comprado um celular por R\$ 1.400,00. Na sexta-feira, tinha recebido seu salário e consumiu tudo em entorpecente. Diante disso, trocou seu celular por 54 porções de crack. Quando estava saindo do local, resetando o aparelho que tinha trocado com o traficante, foi abordado pelos Policiais. O aparelho estava em seu poder ainda porque estava deletando seus dados pessoais. A caixa e a nota fiscal já estava em poder do traficante. Estava com as drogas e o traficante permitiu que ficasse com o aparelho porque estava em frente ao traficante. Tentou destruir um aparelho na Delegacia porque estava com raiva. Foi abordado com dois aparelhos porque um deles pertencia à sua esposa e o outro era seu. Não conhecia os Policiais que efetuaram a sua prisão. Portanto,

Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se, pelo próprio depoimento dos Policiais, que nenhum "ato de comércio" foi visualizado antes da abordagem e não foram apresentados outros indivíduos na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais dos fatos e/ou como possíveis usuários das substâncias entorpecentes. Além disso, a mera afirmação de que o local dos fatos seria um "ponto de tráfico" não é presunção absoluta de dedicação do réu ao comércio de entorpecentes, eis que, nesses locais, também circulam usuários dessas substâncias. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso.

Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso

do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao eu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele

equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

GILSON APARECIDO BEISSMAN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/03, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 07h, na Rua Nelson Camponês do Brasil, nº 96, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína na forma de "crack", pesando cerca de 16,2g (dezesesseis gramas e dois decigramas), e 01 (uma) porção da substância maconha, pesando aproximadamente 5,9g (cinco gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente em um terreno baldio, tentando empreender fuga. Os milicianos, então, foram no encalço de GILSON e apreenderam na posse dele os entorpecentes retro descritos, a quantia de R\$20,00 em espécie e dois aparelhos telefônicos.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 136) e apresentou defesa preliminar (fls. 140/147), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 153/156).

Designada audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, pela fotografia de fls. 16 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 122/124, que trouxe resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito. Disse que é usuário de drogas e não traficante. Afirmou que estava no local dos fatos para comprar entorpecentes, assustou-se quando viu a viatura, adentrou o terreno onde funcionava o ponto de venda de drogas e avisou o "olheiro" do tráfico. Aduziu que o traficante jogou as drogas no chão, correu e conseguiu se evadir.

Disse que foi abordado na sequência. Alegou que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Afirmou que pretendia comprar vinte reais de "crack" e tentar trocar o seu celular por drogas (fls. 05/06).

Em juízo, apresentou versão diversa. Alegou que tinha trabalhado e, dias antes dos fatos, comprou um celular no valor de R\$ 1.400,00. Asseverou passou de sexta para sábado usando drogas e, de sábado para domingo, acabou. Então, trocou o celular por 45 porções de "crack" e o traficante ainda lhe deu R\$ 20,00, porque estava sem dinheiro para comprar isqueiro. Afirmou que saiu do barracão onde o traficante ficava e estava resetando o celular, para apagar seus dados, quando os policiais chegaram e o abordaram. Alegou que tentou se esconder no terreno, mas foi abordado. A duplicidade de versões retira a credibilidade da palavra do réu, posto que essa situação não é compatível com a de quem pode explicar adequadamente os fatos.

A cada momento em que deu sua versão dos fatos, contou uma história diferente, o que reflete negativamente em sua situação, pois caso fosse realmente inocente, não teria necessidade de ofertar versões diferentes a cada vez que fosse ouvido (cf. Apelação 0004859-04.2005.8.26.0481, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12.06.12).

De todo modo, a prova dos autos, porém, é maciça e incriminadora.

O policial militar Gustavo relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Maracanã e, quando entraram na Rua Nelson Camponês do Brasil, avistaram o réu, que, ao notar a viatura, correu para um terreno baldio. Então, foram na direção dele e o abordaram no terreno. Disse que, com o réu, apreenderam 54 pedras de "crack" e uma porção de maconha. Aduziu que o réu ficou em silêncio. Acrescentou que, com ele, foram apreendidos dois celulares e, na delegacia, ele tentou destruir um deles.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Ricardo, ouvido a fls. 04.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais militares não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem apreendido as porções de "crack" e maconha em poder do réu, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, torna certa a autoria.

Prosseguindo, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

E o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Impõe-se, enfim, a condenação do acusado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo as substâncias entorpecentes.

2. Passo à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, observo que o réu é reincidente (fls. 116/121). Esse fato, porém, será analisado na segunda fase de

fixação da pena, evitando-se “bis in idem”. Assim, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, em razão de multireincidência (autos 0000926-37.2017, 0009583-24.2017, 0009588-46.2017 todos da 1ª Vara Criminal local e 0009631-80.2017 desta 4ª Vara Criminal - fls. 116/121), aumento-a de um quinto, resultando seis anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento. De outro lado, em razão da reincidência, o réu não faz jus ao redutor previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o réu reincidente e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória pela prática de crime assemelhado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: “Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PPROCEDENTE o pedido, para condenar GILSON APARECIDO BEISSMAN, qualificado nos autos, à pena de seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, fixado regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário”.

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 31/01/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]